

ROSLINDA BINTI ISHAK
lwn
JOHISHAM BIN JAMALUDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)] Pada 23 Mei 2023 bersamaan 3 Zulkaedah 1444H]

Kes Semakan No. 2302-A0010-003-0020

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguan Pemohon : *Puan Fariah binti Md Isa*
(Tetuan Fariah & Associates.)

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon (Roslinda Binti Ishak) pada 24/2/2023 melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bagi menyemak Perintah Interim Hak Jagaan Anak yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor (YA Hakim Bicara), dalam kes Permohonan No. 10300-028-0057-2022 pada 26/1/2023.

[2] Terma-terma perintah tersebut adalah seperti berikut:

1. *Mahkamah memerintahkan Hak Jagaan Sementara ke atas anak yang bernama Dameo Nur Humairah Binti Johisham (No.KP: 111004-14-0628 dan Dania Aryan Bin Johisham (No.Mykid: 150307-10-0983) hendaklah diserahkan kepada Responden selaku bapa kandung.*
2. *Mahkamah memerintahkan hak lawatan dan bersama tanpa bermalam dierikan kepada Pemohon pada bila-bila masa yang munasabah*

dengan memaklumkan kepada Responden dua (2) hari sebelum sesi lawatan dilakukan.

3. *Mahkamah memerintahkan hak bersama dan bermalam diserahkan kepada Pemohon pada mana-mana minggu pada hari Jumaat jam 7.00 malam sehingga Ahad berikutnya hingga 7.00 malam bergantung kepada kehendak, kerelaan dan kondisi anak-anak tersebut.*
4. *Bagi menyempurnakan hak bermalam ini, Pemohon sendiri hendaklah melihat sendiri kehendak dan kemahuan anak-anak tersebut dan memaklumkan kepada Responden dua (2) hari sebelum hak bermalam dilakukan.*
5. *Mahkamah memerintahkan hak bersama pada cuti persekolahan hendaklah dibahagikan sama rata antara pihak-pihak.*
6. *Kedua-dua pihak hendaklah memaklumkan dan berbincang berkaitan kebajikan anak-anak tersebut dari semasa ke semasa.*
7. *Hak pada hari Raya adalah bergilir sebagaimana ketetapan berikut:*
 - i. *Pada Hari Raya Aidilfitri 2023 (1444H), anak-anak tersebut akan bersama Responden sehingga Hari Raya Kedua jam 7.00 malam dan bersama Pemohon berikutnya sehingga jam 7.00 malam hari raya Kelima.*
 - ii. *Pada Hari Raya Aidilfitri 2024 (1445H), anak-anak tersebut akan bersama Pemohon sehingga Hari Raya Kedua jam 7.00 malam dan bersama Pemohon berikutnya sehingga jam 7.00 malam Hari Raya Kelima.*
 - iii. *Pada Hari Raya Aidiladha 2023 (1444H), anak-anak tersebut akan bersama dengan Pemohon sepenuhnya dan Pemohon boleh*

mengambil anak-anak tersebut pada jam 10.00 pagi sehari sebelumnya.

iv. Pada Hari Raya Aidiladha 2024 (1445H), anak-anak tersebut akan bersama dengan Responden sepenuhnya.

- 8. Mahkamah memerintahkan Pemohon dan Responden dan/atau ahli keluarga masing-masing adalah dilarang dan ditegah daripada mengganggu atau mencero boh atau memburuk-burukkan, menghina, mengeji dan/atau mengaibkan mana-mana pihak di hadapan anak-anak tersebut.*
- 9. Pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) hendaklah membantu pelaksanaan dan penguatkuasaan perintah jagaan sementara ini.*
- 10. Perintah ini hendaklah berkuat kuasa sehingga kes induk Saman No.: 10300-028-0057 Tahun 2022 diputuskan atau ada apa-apa perintah lain yang membatalkannya.*

[3] Berdasarkan Notis Permohonan semakan ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah ini untuk mendapatkan perintah-perintah seperti berikut:

- i. Bahawa suatu semakan dibuat terhadap perintah yang dibuat oleh YA Hakim Bicara dalam Kes Permohonan No: 10300-038-0058-2022 berdasarkan seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor).*

- ii. Bahawa Mahkamah ini membatalkan dan/atau mengubah Perintah bertarikh 26/1/2023 dalam Kes Permohonan No: 10300-038-0058-2022.
- iii. Bahawa perintah ini berkuat kuasa sehingga perintah hak jagaan kekal dalam Kes Saman No: 10300-028-0057-2022 diputuskan.
- iv. Bahawa Mahkamah ini memerintahkan Kes Saman No: 10300-028-0057-2022 hendaklah dibicarakan di hadapan Hakim yang lain.
- v. Apa-apa relif yang patut dan wajar diberikan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 24/12/2010 dan bercerai di luar dan tanpa kebenaran mahkamah pada 4/5/2017. Hasil perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan dua orang anak iaitu:

- i. Damea Nur Humairah Binti Johisham (tarikh lahir: 4/10/2011)
- ii. Danial Aryan Bin Johisham (tarikh lahir: 7/3/2015)
(selepas ini dikenali sebagai “anak-anak tersebut”)

[5] Pada 24/1/2022 Pemohon telah memfailkan suatu permohonan interim hak jagaan anak secara *inter parte* melalui Kes Permohonan No: 10300-038-0058-2022 dan kemudiannya kes hak jagaan kekal difailkan pada 25/1/2022 melalui Kes Mal No: 10300-028-0057-2022. Bagi kes interim tersebut, YA Hakim Bicara telah

membuat keputusan sebagaimana terma-terma yang dinyatakan pada perenggan [2] di atas. Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, maka semakan ini difailkan.

ALASAN SEMAKAN

[6] Merujuk kepada Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan, Pemohon-Pemohon menyatakan alasan-alasan kepada semakan ini yang dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

- i. YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak menimbangkan fakta bahawa Pemohon adalah ibu kandung kepada anak-anak tersebut dan tidak pernah pada bila-bila masa telah hilang kelayakan sebagai penjaga.
- ii. YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memberikan hak jagaan kedua-dua anak tersebut kepada Responden tanpa sebarang alasan yang munasabah.
- iii. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dan terkeliru apabila menyatakan dalam penghakimannya bahawa Pemohon telah memohon perintah menahan atau menghalang Responden daripada membuat kacau-ganggu sedangkan Pemohon tidak pernah memohon perintah sedemikian.
- iv. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dan terkeliru dari sudut fakta dan pihak-pihak yang dirujuk apabila menyatakan bahawa permohonan asal dibuat secara *ex-parte* tetapi telah diarahkan untuk dibuat secara *inter*

parte, sedang Pemohon tidak pernah membuat permohonan secara *ex-parte*.

- v. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam keputusan apabila kupasan yang dibuat kepada isu pertama dalam penghakimannya menunjukkan Pemohon adalah orang berkeelayakan sebagai penjaga, namun perintah yang dikeluarkan telah memberikan hak jagaan kepada Responden.
- vi. YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak mempertimbangkan *status quo* penjagaan anak-anak tersebut yang telah tinggal dengan Pemohon sejak dari kecil sehinggalah keputusan hak jagaan sementara dikeluarkan.
- vii. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dan terkeliru apabila perintah yang dibuat pada perenggan 1 bercanggah dengan perenggan 4 di mana Pemohon selaku orang yang hanya diberi akses melawat perlu melihat sendiri kemahuan dan kehendak anak yang bukan dalam jagaannya sebelum hak bermalam dilaksanakan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Dalam menjalankan kuasa semakan Mahkamah Rayuan Syariah, kami merujuk peruntukan Seksyen 68(1)Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003] yang menyatakan –

Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika nampaknya dikehendaki demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenainya dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

[8] Berdasarkan peruntukan di atas, Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah sama ada atas kehendaknya sendiri atau mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding demi kepentingan keadilan.

[9] Dengan hormatnya, kami merujuk kepada prinsip semakan yang merupakan satu proses yang bertujuan untuk memperbetul atau menghalang kesilapan sebagaimana panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes **Mokhtar bin Yusup lwn. Nurin binti Abdullah [2013] JH36(2)** yang antara lain menyatakan:

“Proses semakan adalah semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi nas-nas Syarak yang qat’ie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuat kuasa.”

[10] Prosiding semakan juga adalah suatu proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-

pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[11] Oleh itu, sebelum pertimbangan lanjut diberikan kepada permohonan ini, terlebih dahulu kami perlu memastikan sama ada alasan-alasan yang dikemukakan adalah bersesuaian untuk proses semakan ini digunakan atau sebaliknya. Hal ini memandangkan sesuatu permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 ini tidaklah wajar dibenarkan tanpa justifikasi undang-undang yang kukuh.

[12] Sukacita untuk kami menarik perhatian pihak-pihak kepada kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (semakan) No. 14000-003-0033-2012 di Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dalam kes ini Panel Rayuan telah menegaskan kes-kes yang boleh disemak adalah sebagaimana berikut:

i. Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;

ii. Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-

a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;

b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

[13] Selain itu, kami turut dipandu oleh Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 yang telah kami jelaskan. Dalam konteks kes semakan ini, perenggan 5 dan 7 berikut adalah relevan iaitu:

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*

[14] Berdasarkan panduan yang diberikan dalam Arahan Amalan ini, adalah jelas menunjukkan keputusan yang bersifat interim boleh disemak sekiranya berlaku dua perkara iaitu pertama kecacatan tatacara perbicaraan dan yang kedua keputusan yang dibuat secara materialnya adalah bercanggah dengan undang-undang dan hukum Syarak. Merujuk kepada alasan-alasan yang dikemukakan, pada hemat kami hanya dua alasan sahaja yang dibangkitkan boleh dikaitkan secara langsung dengan kedua-dua kecacatan yang dimaksudkan iaitu:

- i. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dan terkeliru apabila menyatakan dalam penghakimannya bahawa Pemohon telah memohon perintah menahan atau

menghalang Responden daripada membuat kacau ganggu sedangkan Pemohon tidak pernah memohon perintah sedemikian.

- ii. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dan terkeliru dari sudut fakta dan pihak-pihak yang dirujuk apabila menyatakan bahawa permohonan asal dibuat secara *ex-parte* tetapi telah diarahkan untuk dibuat secara *inter parte*, sedang Pemohon tidak pernah membuat permohonan secara *ex-parte*.

Manakala alasan-alasan lain adalah menjurus kepada persoalan merit yang pada hemat kami sewajarnya dibangkitkan semasa perbicaraan penuh hak jagaan kekal bagi memberikan ruang kepada kedua-dua pihak mengemukakan keterangan dan hujah.

[15] Bagi memutuskan kedua-dua persoalan ini, kami telah memanggil dan membuat penelitian kepada rekod Kes Permohonan No. 10300-038-0058-2022 dan mendapati tiada permohonan dibuat oleh Pemohon untuk mendapatkan perintah menahan atau menghalang Responden daripada membuat kacau ganggu. Pada hemat kami sekalipun tiada permohonan khusus dibuat, ia tidak menghalang YA Hakim Bicara mengeluarkan perintah sedemikian memandangkan YA Hakim Bicara mempunyai kuasa untuk mengeluarkan apa-apa relif yang difikirkan patut dan wajar bagi memastikan perintah yang dikeluarkan adalah teratur dan dapat dilaksanakan dengan sempurna.

[16] Dalam mengulas isu ini, kami telah merujuk kepada peruntukan seksyen 197 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan seperti berikut:

Kuasa Mahkamah untuk memberikan perintah interim

197. (1) Tertakluk kepada Bab ini, Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa mengikut budi bicaranya, untuk memberikan apa-apa perintah interim atas apa-apa terma yang difikirkannya patut dan boleh memberikan apa-apa arahan tentang prosiding selanjutnya.

[17] Peruntukan ini secara jelas memberikan kuasa kepada Mahkamah untuk mengeluarkan apa-apa perintah interim mengikut budi bicaranya atas apa-apa terma yang difikirkan oleh Mahkamah adalah patut. Frasa “*memberikan apa-apa perintah interim*” menunjukkan bahawa tidak wujud halangan kepada Mahkamah untuk memberikan apa-apa perintah dalam sesuatu prosiding kes yang sedang berjalan sekiranya Mahkamah merasakan adanya keperluan untuk berbuat demikian. Justeru, dalam isu ini kami tidak menganggap perintah yang dikeluarkan berkaitan dengan kacau ganggu ini sebagai suatu kecacatan.

[18] Dari sudut permohonan pula, kami berpuas hati sungguhpun dalam alasan penghakimannya, YA Hakim Bicara ada mengaitkan permohonan yang dibuat adalah bermula dengan *ex-parte*, namun penelitian kami mendapati ia hanya kekhilafan penulisan dalam alasan penghakiman sahaja sedangkan prosiding sebenar telah dijalankan secara *inter-parte* sedari awal sehinggalah keputusan dibuat. Begitu juga dengan kekeliruan berkenaan pihak-pihak dalam alasan penghakiman yang dibangkitkan oleh Pemohon, kami turut berpuas hati hasrat sebenar YA Hakim Bicara adalah untuk memerintahkan hak jagaan sementara adalah kepada Responden selaku bapa kandung. Oleh yang demikian, kami tidak melihat isu ini telah mencatatkan prosiding kes.

[19] Bagi menentukan sama ada keputusan yang dibuat bercanggah dengan hukum Syarak atau undang-undang atau sebaliknya, kami telah membuat penelitian kepada

asas pertimbangan yang telah dibuat dan mendapati YA Hakim Bicara telah memberikan hak jagaan sementara kepada Responden setelah mengambil kira pilihan yang dibuat oleh kedua-dua anak tersebut dan status Responden selaku penjaga hakiki selaras dengan kehendak peruntukan seksyen 89(1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[20] Berdasarkan kepada pertimbangan tersebut, kami berpendapat YA Hakim Bicara telah memberikan asas kepada keputusan yang dibuat tanpa menafikan kelayakan kedua-dua pihak untuk mendapat hak jagaan. Sekalipun kelayakan Pemohon sebagai *hadinah* tidak gugur, ia tidak bermakna hak jagaan sepatutnya terus diberikan kepada Pemohon sebaliknya terdapat pertimbangan-pertimbangan lain perlu diberikan perhatian yang menjadikan hak jagaan sementara lebih utama diberikan kepada Responden demi menjaga kemaslahatan dan kebajikan anak-anak tersebut. Dalam konteks kes ini, kami mendapati YA Hakim Bicara telah berpandukan kepada pilihan anak yang telah *mumaiyyiz* dalam menentukan kepentingan dan kebajikan anak.

[21] Berhubung dengan isu kemaslahatan ini, sukacita kami merujuk kepada pandangan yang dijelaskan oleh Syed Sabiq di dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah, Juz 8 halaman 219* yang menyatakan:–

إن لكل من الحضانة والمحضون حقاً في الحضانة, إلا أن حق المحضون أقوى من
الحضانة

“Sesungguhnya setiap penjaga dan anak jagaan masing-masing mempunyai hak. Akan tetapi hak anak atau kemaslahatan anak lebih penting dari hak penjaganya”

[22] Perkara yang sama juga telah diulas oleh Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan di dalam kes Mohd Radhi bin Haji Che Daud lwn Khadijah binti Yaacob[2004] JH 17(1) iaitu:–

“Tujuan hadhanah atau penjagaan kanak-kanak ialah untuk masalah dan kebaikan kanak-kanak yang dipelihara sebagai hak asasi bagi kanak-kanak itu dan hak itu mesti diutamakan lebih dari hak pihak yang ingin memelihara mereka.”

[23] Pada hemat kami juga YA Hakim Bicara telah mengguna pakai prinsip *masalah* dan kebajikan anak-anak tersebut apabila memberikan hak bersama, melawat dan bermalam kepada Pemohon bagi memastikan hubungan seorang ibu dan anak sentiasa berterusan. Melalui perenggan 4 perintah yang dikeluarkan, inti pati utamanya adalah Pemohon tertakluk kepada kehendak dan kesediaan anak-anak tersebut bagi menjalankan hak untuk bermalam. Hal ini bagi memastikan pelaksanaannya dibuat secara sukarela dan tanpa paksaan mahupun halangan daripada kedua-dua pihak. Berdasarkan dapatan ini, kami tidak melihat wujudnya percanggahan antara perintah pada perenggan 1 dan 4 sebagaimana yang didakwa oleh Pemohon bagi mewajarkan semakan ini dibenarkan.

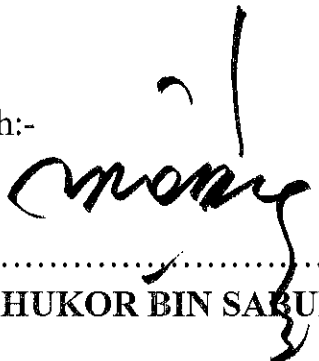
[24] Berdasarkan ulasan-ulasan di atas, kami bersetuju bahawa Pemohon gagal menunjukkan kepada kami kekhilafan YA Hakim Bicara yang secaranya materialnya bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sama ada dari sudut tatacara ataupun keputusan akhir yang dibuat. Oleh yang demikian, dengan mengambil kira perintah yang dikeluarkan adalah untuk suatu tempoh sementara, maka pada peringkat ini kami tidak berhasrat untuk mengganggu perintah yang telah dikeluarkan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan Pemohon-Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Permohonan semakan Pemohon **DITOLAK**.
2. Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dalam kes Permohonan No. 10300-038-0058-2022 pada 26/1/2023 **DIKEKALKAN**.

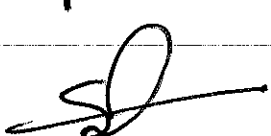
Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
-
1. **Y.A.A DATO' MOHD SHUKOR BIN SARUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **Y.A. DATUK MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor